

1503137-28.2021.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Glaucio Roberto Brittes de Araujo

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/08/2022

... Com efeito, não há prova suficiente de dedicação ao tráfico. Não foram encetadas diligências exitosas sobre o vínculo permanente do réu com a criminalidade. Sob o crivo do contraditório, não se demonstrou, de maneira inequívoca, a dedicação atual à atividade criminosa, mormente tráfico, que o distinguisse do traficante iniciante ou "de primeira viagem".

À mingua de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

4ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503137-28.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503137-28.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2335555/2021 - 02º D.P. GUARULHOS, 21865643 - 02º D.P. GUARULHOS, 2835/21/207 - 02º D.P. GUARULHOS, 2335555 - 02º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ISAAC PEREIRA SANTOS

Juiz de Direito: Dr. Glaucio Roberto Brittes de Araujo

VISTOS.

ISAAC PEREIRA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado

como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 09 de dezembro de 2021, por volta das 10 horas, na Rua Maria Guilhermina, altura do nº 100, bairro Cabuçu, nesta cidade e Comarca de Guarulhos, trazia consigo e guardava, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 67 (sessenta e sete) invólucros plásticos contendo Cannabis Sativa L, substância vulgarmente conhecida como "maconha", com peso líquido de 135,13g, 343 (trezentos e quarenta e três) invólucros plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 100,04g, e 60 (sessenta) invólucros plásticos contendo cocaína na forma petrificada (crack), com peso líquido de 7,95g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (Auto de Exibição e Apreensão a fls. 07/08 e Laudo de Constatação a fls. 26/31).

A denúncia foi oferecida. O réu foi notificado e apresentou resposta à acusação. A denúncia foi recebida e, não sendo o caso de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns à acusação e defesa, seguindo-se o interrogatório do acusado.

Superada a fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, em alegações finais, a representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos termos da denúncia. No tocante à dosimetria, manifestou-se pela possibilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado, no patamar intermediário, em razão da natureza das drogas, com substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e regime inicial aberto.

A Defesa, por sua vez, postulou a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII do CPP e, subsidiariamente, desclassificação para o artigo 28 da Lei 11343/06, fixação da pena base no mínimo legal, aplicação do redutor, regime aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, recurso em liberdade e concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade e a autoria de delito ficaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo de constatação provisória, pelo laudo do exame químico-toxicológico definitivo e pela prova oral colhida.

A quantidade, a variedade, a forma de acondicionamento das drogas, a quantia em dinheiro apreendida R\$17,00 (fls. 7) e as circunstâncias da posse evidenciam que o entorpecente seria fornecido a terceiros. A conduta corresponde, perfeitamente, ao tipo penal do art. 33, da Lei 11.343/06. A autoria é igualmente indubitosa, considerando todo o conjunto probatório.

O réu negou vagamente a prática delitiva, alegando que estava no local, porque tinha acabado de pegar duas trouxas de cocaína e uma maconha, como costumava fazer. Afirmou que trazia sua mochila com documentos e pertences pessoais, sem as drogas mencionadas. Destacou que havia outras duas mochilas no local da abordagem, uma com dinheiro e outra com entorpecentes, pois foram abandonadas pelos indivíduos que fugiram. Declarou que os policiais lhe imputaram as drogas, colocando-as na sua mochila, porque 15 (quinze) dias antes o tinham surpreendido no mesmo local comprando entorpecente. Não indicou nenhum motivo concreto para tal armação e falsa incriminação. Afirmou que não usa mais cocaína e não tem crise de abstinência. Está trabalhando com gesso e é primário.

A versão vaga, isolada e inverossímil acabou refutada pelas provas colhidas, enquanto a imputação encontrou sólido respaldo probatório. Vejamos.

A testemunha Antônio afirmou que, com viatura descaracterizada em conhecido ponto de vendas, avistaram quatro indivíduos e fizeram abordagem. Três empreenderam fuga, mas o réu permaneceu no local e aos seus pés havia uma mochila, onde localizaram grande quantidade de maconha, cocaína e alguns vidros de lança perfume. Lembrou-se do dinheiro, mas não de onde tinha sido localizado. Aduziu que ele negou a propriedade do entorpecente, mas que na mochila estavam também os seus documentos pessoais. Ele alegou apenas que era usuário.

A policial Carolina afirmou que, na viatura descaracterizada em conhecido ponto de tráfico, avistaram quatro rapazes, que revelaram nervosismo. Ao serem abordados, três deles fugiram. Perto do réu havia uma mochila, onde localizaram grande quantidade e variedade de drogas. Ele alegou ser usuário, mas na mochila estavam os seus documentos pessoais. Não apresentou justificativa para aquela situação e posse de tantas drogas, tendo dito informalmente que estava trabalhando na época, embora desmentido no DP por seu pai, segundo o qual, há muito tempo ele não aparecia para trabalhar. Não explicou também de quem adquiriria drogas e com qual dinheiro.

Como se percebe, os fatos narrados na exordial acusatória restaram devidamente comprovados. Na data aludida, o acusado trazia consigo e guardava uma mochila contendo pertences e documentos pessoais, além das drogas acima descritas, para fins de entrega ao consumo de terceiros. Embora acompanhado de outros três agentes não identificados, a mochila com drogas lhe pertencia e estava aos seus pés, não se sabendo sua vinculação com o trio que fugiu. A despeito das evidências de liame de todos com o tráfico no local, não é determinante tal fator para comprovação da conduta típica do réu. Foi surpreendido com o entorpecente em situação de destinação a outrem e jamais ofereceu explicação plausível para tanto.

Importa que os policiais, em diligências no local, em viatura descaracterizada, avistaram os quatro agentes, que revelaram nervosismo. Sintomaticamente, os três agentes não identificados fugiram e o acusado foi detido. A mochila contendo as drogas acima descritas foi apreendida aos seus pés e, além dos entorpecentes descritos, continha 06 (seis) vidros contendo substância líquida semelhante à substância conhecida como “lança-perfume” e os documentos pessoais do acusado. Não apresentou justificativa para os documentos estarem com as drogas e nem as imputou a terceiros ou ofereceu dados para identificação daqueles outros. Não logrou apresentar elementos concretos para refutar as evidências da posse e do dolo, curiosamente.

Outrossim, no caso em apreço, os testemunhos atestaram, em uníssono, com detalhes, coerência e firmeza, a posse das drogas pelo réu em situação de comércio, denotando plena adesão ao tráfico, enquanto a defesa não soube relatar dinâmica diversa convincente e não cogitou de motivo para ser incriminado falsamente.

Não é crível, outrossim, que a grande quantidade de maconha e cocaína se destinaria apenas ao uso pessoal, sobretudo em local público. A alegação vaga, isolada e ulterior foi rebatida pelas evidências do dolo e da autoria desse crime. Não obstante os argumentos da Defesa, as provas da dinâmica dos fatos exposta na exordial são fartas, ao passo que a versão do interrogatório judicial não se mostrou dotada de sentido lógico e respaldo indiciário mínimo. Não é crível que os policiais transfeririam as drogas da mochila do traficante para a do réu tão somente porque o surpreenderam novamente comprando entorpecente.

Além disso, não há razão concreta para desprezar as declarações de testemunhas sob compromisso formal, inclusive sobre o liame subjetivo com as drogas. Saliente-se que merecem crédito e são dotados de valor probatório determinante, em delitos de tal jaez. Nesse sentido, há farta jurisprudência:

"O valor de depoimento testemunhal de policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF, HC nº 73.518-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.1996).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA FUNDAMENTADA. CONDENAÇÃO AMPARADA EM TESTEMUNHOS PRESTADOS POR POLICIAIS. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. (...) 2. Não há óbice a que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu sejam considerados na sentença como elemento de prova amparador da condenação, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de cognição, tal como na hipótese, em que a expressiva quantidade de droga apreendida - 24 (vinte e quatro) invólucros com crack - revela não ser o entorpecente destinado a consumo próprio. 3. Tem-se por adequado o regime fechado para o início do cumprimento da pena corporal de 5 (cinco) anos aplicada ao paciente pelo tráfico de drogas, dado o estabelecimento da pena-base acima do mínimo legal em conta do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas, não se olvidando a quantidade de entorpecente que trazia consigo. 4. Ordem denegada." (STJ, HC n.º 223086 / SP; 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 19.11.2013).

E o decreto condenatório não se baseia tão somente na palavra de policial ou nos dados do inquérito. No caso concreto, todos os elementos probatórios harmonizam-se, inclusive aqueles obtidos na fase judicial sobre a dinâmica da obtenção dos elementos sensíveis da infração, sendo certo que o magistrado pode utilizar todos na formação de seu convencimento. Ainda que assim não fosse, não há óbice à valoração, embora relativa, dos elementos colhidos na fase de investigação para fundamentar eventual decreto condenatório, porquanto a vedação legal é no sentido da impossibilidade de condenação lastreada exclusivamente em tais provas, nos exatos termos do art. 155 do CPP. Neste sentido, é a jurisprudência:

"(...) Mostra-se válida a condenação imposta com auxílio de dados obtidos na fase inquisitorial se tais estão em consonância com o apurado em juízo. O desprezo ao que se produziu na fase investigativa não é possível por força do princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, adotado em nosso ordenamento. Portanto, ainda que tenha a princípio menor valor o elemento produzido no caderno inquisitivo, por força do disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, não pode tal ser afastado de pronto. No caso dos autos a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, confirma e corrobora a prova produzida tão somente no inquérito policial. Assim a prova deve ser vista como um todo, não se considerando o lugar onde foi produzida, mas o valor probante, estando garantido os direitos constitucionais do réu, conforme acima exposto". (TJ/SP, Apelação nº 0039765-66.2010.8.26.0506, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Lauro Mens de Mello, j. 28/04/2016).

Nesse sentido, os relatos dos policiais devem prevalecer sobre a impugnação da defesa, pois foram coerentes nas duas fases processuais, minuciosos, harmônicos, seguros e condizentes com os elementos sensíveis da infração. Não havia motivos, a propósito, para incriminarem falsamente um desconhecido. Também não surgiram indícios de que a droga pertencesse a outrem ou de equívoco no flagrante.

No mais, em delitos de tal natureza, as evidências são determinantes para elucidação do vínculo subjetivo entre o agente e as drogas e de sua destinação,

sendo inviável prova concreta e cabal do seu pensamento. De outro lado, não se alegou pronta e espontaneamente e não ficou evidenciado que toda aquela droga apreendida seria consumida.

De qualquer sorte, a quantidade, a variedade e forma de acondicionamento da droga e as circunstâncias da ação revelaram sobejamente a destinação a terceiros. Incabível, pois, eventual tese de insuficiência de provas ou desclassificação para art. 28, da lei. O acusado não estava apenas com três porções de drogas, como alegou, mas com grande volume, pronto para entrega. Assim, praticou os atos típicos descritos na norma penal invocada na denúncia. Justificativas relativas à situação econômica ou de vício, ainda que, em tese, tivessem contribuído para a traficância, não são dirimentes da ilicitude ou da culpabilidade. Não autorizam a despicienda ofensa ao bem jurídico.

Finalmente, nenhum álibi restou comprovado de maneira inequívoca e nenhuma excludente ficou configurada. Não pairam dúvidas sobre o liame subjetivo entre o réu e as drogas encontradas e sobre a finalidade de fornecimento a outrem.

Portanto, comprovada a materialidade delitiva e evidenciada a autoria, ante o complexo probatório robusto e coerente produzido nos autos, impende apreciar a dosimetria da pena, fixando-a no patamar suficiente e necessário à reprovação do delito.

Bem sopesados os elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase, fixo a pena-base no mínimo legal, consistente em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, considerando a primariedade do acusado (fls. 35).

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, tendo em vista a primariedade do réu e a ausência de prova de envolvimento em organização ou dedicação à atividade criminosa, adota-se a causa de diminuição do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 em 1/3, totalizando 3 anos e 4 meses de reclusão e 333 dias-multa. Com efeito, não há prova suficiente de dedicação ao tráfico. Não foram encetadas diligências exitosas sobre o vínculo permanente do réu com a criminalidade. Sob o crivo do contraditório, não se demonstrou, de maneira inequívoca, a dedicação atual à atividade criminosa, mormente tráfico, que o distinguisse do traficante iniciante ou “de primeira viagem”.

À míngua de critérios seguros e explicitamente estabelecidos para a aplicação do art. 33, par. 4, da Lei 11343/06, o art. 42 do referido diploma legal deve orientar o patamar daquela redução. Restringir este preceito à fase do art. 59, do Código Penal, a par de despiciendo, criaria distinção injustificada em relação a outros delitos, na primeira etapa de dosimetria da pena, e não permitiria solução eficaz para a controvérsia acerca dos critérios de redução da terceira fase.

Por conseguinte, no caso em apreço, ante a quantidade e a natureza de parte da droga, não se exige a redução máxima, estando preservado o prudente arbítrio do julgador. A propósito, a lei estabelece somente que as penas “poderão” ser reduzidas. Além disso, entende-se que por se tratar de causa de redução como simples benefício – que já pode ir aquém do mínimo legal – e não de dosimetria da primeira fase, não se adota a pena menor em perspectiva (diminuição máxima) como regra. Muito pelo contrário, a legislação recente destinou-se ao agravamento da coibição, da repressão e da resposta penal para o tráfico de entorpecentes, sendo ilógica e dissociada do princípio da razoabilidade a exigência peremptória da diminuição máxima da pena, que a levaria a um patamar muito inferior ao da lei antiga.

Segundo exegese sistemática e teleológica das normas sobre a matéria, o percentual

de diminuição deve ser escolhido de acordo com o caso concreto e a especificidade do potencial lesivo da conduta, como possível número de usuários em perspectiva. Ausente prova de efetivo comando e gerência na região, por outro lado, descabida a redução mínima da sanção.

Assim, para a pena definitiva de 3 anos e 4 meses de reclusão, cabe o regime inicial aberto para o cumprimento, tendo em vista ainda o "privilégio", a natureza do crime (sem violência ou ameaça que poderia exigir o fechado) e as circunstâncias favoráveis do artigo 59, do CP. Por se tratar de tráfico de drogas privilegiado, cumpre observar decisões recentes dos Tribunais Superiores no sentido de que o referido crime não é hediondo e enseja regime compatível com a quantidade da pena, sem prejuízo da possibilidade de outro mais gravoso (aqui aberto) em razão de fatores específicos, ausentes no caso concreto. Sobre a temática, confira-se:

"EMENTA PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDIVIDUAL E COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DIRETRIZES REGISTRADAS PELA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641 (PLENO). PRECEDENTES DESTES TRIBUNAL DA CIDADANIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HIPÓTESES DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, LEI N. 11.343/2006). TRÁFICO. DEFINIÇÃO LEGAL (ART. 112, §5º, LEI N. 7.210/1984). CRIME NÃO HEDIONDO. CONECTIVOS LÓGICOS EM RAZÃO DESSE RECONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E SÚMULAS DE JURISPRUDÊNCIA. FORÇA NORMATIVA. ESTUDO DO INSTITUTO CONECTAS E DADOS ESTATÍSTICOS QUE CONFIRMAM O DESCUMPRIMENTO REITERADO PELO TRIBUNAL IMPUGNADO. DESRESPEITO AO SISTEMA DE PRECEDENTES. SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE. ISONOMIA DO JURISDICIONADO. BUSCA À RACIONALIDADE PUNITIVA. PREDICATIVO ÍNSITO AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REGIME PRISIONAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE". (STJ, HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1) - Decisão Monocrática- Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA).

Ademais, tal conclusão também decorre da Lei de Execuções Penais, com as alterações trazidas pelo pacote anticrime (Lei n.º 13.964/2019), mais precisamente da redação art. 112, § 5º da LEP: "Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006."

Preenchidos, por conseguinte, os requisitos do art. 44 do CP, à luz da pena aplicada e da primariedade, sendo ainda socialmente recomendável, concede-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena a uma entidade com função social, e prestação pecuniária de um salário-mínimo especificadas oportunamente pelo juízo da execução.

Ante todo o exposto, e considerando tudo o mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a pretensão do Órgão Ministerial para CONDENAR o réu ISAAC PEREIRA SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, cc par. 4, da Lei nº 11.343/06, na pena privativa de liberdade de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por prestação gratuita de serviços à comunidade pelo mesmo prazo e prestação pecuniária de um salário-mínimo a entidade com função social, em condições especificadas na execução, além de 333 dias-multa pelo valor unitário mínimo.

O réu poderá apelar em liberdade, pois concedida a substituição da pena privativa por restritiva de direitos.

Transitada esta em julgado, far-se-á a necessária comunicação ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para o fim previsto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Declaro o perdimento do dinheiro em favor da União, ante as evidências do liame com

o tráfico, e determino a incineração da droga apreendida.

Custas e despesas processuais pelo sentenciado, observada a gratuidade.

P.I.C.

Guarulhos, 01 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA